

《【문제14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 '소멸시효 항변'을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 '상계항변'을 추가로 제출하고자 한다.

(물음2) 항소심에서 변론의 범위는 제1심 변론과 어떻게 연결되는지(변론의 집중)를 설명하고, 乙이 추가로 제출하려는 '상계항변'이 항소심의 심리 단계에서 어느 정도까지 허용되는지 판례가 제시하는 '적시제출의 원칙'과 관련하여 기술하시오.》

<문제14.3의 물음2> 항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 항소심 계속 중 제1심에서 주장하지 않았던 상계항변을 추가로 제출하려는 상황이다. 쟁점으로 <항소심에서의 변론 범위와 변론의 집중>에 따른 새로운 공격방어방법 제출의 허용 여부 및 적시제출의 원칙에 따른 제한을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 추가한 상계항변의 허용 범위와 그 제출 제한 여부를 기술한다.

II. 항소심 변론의 범위와 제1심과의 연결

1. 변론의 일체성 (단일성)

(1) 의의

- 항소심의 변론은 제1심 변론의 속행으로서, 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 가진다. 이를 변론의 일체성 또는 단일성이라 한다.

(2) 변론의 집중과 속심제

- 항소심은 제1심의 심리를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 판결한다. 따라서 당사자는 원칙적으로 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있다.

2. 변론의 집중을 위한 제한

- 실질적으로 항소심이 제1심의 반복이 되는 것을 방지하고 재판의 신속을 기하기 위하여, 민사소송법은 적시제출주의(제146조)를 근거로 실기한 공격방어방법의 각하(제285조, 제412조) 규정을 두고 있다. 이는 항소심에서의 무분별한 새로운 주장 제출을 억제하는 기능을 한다.

III. 상계항변의 제출과 적시제출의 원칙

1. 상계항변의 특수성

- 상계항변은 소송 외적인 채권·채무 관계를 소송 내로 끌어들이 심리하는 것으로, 다른 방어방법에 비해 심리가 복잡해질 가능성이 크다. 따라서 이를 뒤늦게 제출하는 경우 소송 지연의 우려가 더 높게 평가될 수 있다.

2. 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

(1) 각하 요건

- ❶ 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적기에 제출하지 않았어야 한다. ❷ 그 방어방법의 제출로 인하여 소송의 완결이 지연되어야 한다.

(2) 판례의 태도

- "판례"는 상계항변이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 제출된 경우, 그것이 소송의 상태에 비추어 새로운 증거조사를 필요로 하거나 심리 기일을 연장시키는 결과를 초래한다면 실기한 공격방어방법으로서 각하될 수 있다고 본다.

(3) 판단 기준

- "판례"에 따르면 소송의 완결을 지연시키는지 여부는 그 방어방법을 각하했을 때 소송이 즉시 종결될 수 있는 상태인지를 기준으로 판단한다. 즉, 이미 심리가 충분히 이루어져 판결을 내릴 수 있는 단계에서 새로운 상계항변이 제출되어 추가적인 심리가 필요하다면 이는 지연으로 간주된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상계항변 제출 시기

- 乙은 제1심에서 대여사실만을 부인하다가 항소심 진행 중에 비로소 5,000만 원의 채권을 근거로 상계항변을 제출하려 한다. 상계의 기초가 되는 채권이 제1심 당시 이미 존재하고 있었고 乙이 이를 인지하고 있었다면, 이를 항소심에서야 제출하는 것은 고의 또는 중대한 과실에 의한 지연으로 평가될 가능성이 높다.

2. 소송 지연의 실질적 판단

- 사안에서 항소심 재판부가 이미 새로운 증인 丙의 진술을 핵심 열쇠로 판단하여 심리를 진행 중인 상황이라 하더라도, 乙이 제출하려는 상계항변이 별개의 채권 존재 여부를 다투어야 하는 등 추가적인 증거조사를 필요로 한다면 이는 명백히 소송의 완결을 지연시키는 사유가 된다. 특히 상계항변은 반대채권의 존부에 대한 심리가 선행되어야 하므로 소송 경제 측면에서 엄격히 제한될 수 있다.

V. 결론

- 乙의 상계항변은 항소심이 속심제라는 점에서 원칙적으로 제출 가능하나, "판례"가 제시하는 적시제출의 원칙에 따라 엄격한 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었던 사정(고의·중과실)이 인정되고, 해당 항변으로 인해 기존에 예정된 항소심 판결 시기가 늦춰진다면(소송 지연), 법원

은 "민사소송법 제412조" 및 "제285조"를 적용하여 이를 각하하여야 한다. 이는 항소심을 사실상의 제2의 제1심으로 오용하는 것을 방지하고 변론의 집중을 실현하기 위한 필수적인 조치이다.